

1500549-69.2022.8.26.0452

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... possível alusão à contabilidade do tráfico. Foi apreendida quantia em espécie no armário da sala, quantia que, por si só, não é indicativa de traficância. A quantidade de crack apreendida também não era expressiva. O acusado guardava 6,98g de crack (massa líquida), fracionada em quatorze porções.

Enfim, nenhum ato inequívoco de tráfico foi visualizado. Aliás, os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500549-69.2022.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-69.2022.8.26.0452

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173766/2022 - DEL.POL.PIRAJU, 25795229 - DEL.POL.PIRAJU, 2173766 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DORNÉLIO MARCELO LEME

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra DORNÉLIO MARCELO LEME (fls. 89/91), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

Consta do incluso inquérito policial que, no 27 de junho de 2022, por volta de 23h15min, na Rua Sebastião Vaz Pereira, Vila Diana, nesta cidade e comarca de Piraju, DORNÉLIO MARCELO LEME, qualificado à fl. 11, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 14 pedras de crack, com 7,93g de massa líquida, droga proscrita<sup>1</sup>, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais) em espécie (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 16 e laudo definitivo de fls. 80/83). Segundo se apurou, havia mandado de prisão expedido contra o denunciado referente aos autos nº 1500029-80.2020.8.26.0452.

Na data dos fatos, os policiais encontraram o denunciado em via pública e o abordaram, dando cumprimento ao mandado.

Após, foram até a residência do denunciado, e, em busca domiciliar após a

autorização de entrada, os policiais localizaram 14 pedras de crack, R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais), juntamente com outros objetos de procedência duvidosa, que foram apreendidos.

Diante disso, as circunstâncias da prisão, a maneira como as drogas estavam embaladas, separadamente, prontas para venda e o dinheiro apreendido revelam que ele efetivamente praticava o tráfico de drogas. (fl. 90).

Regularmente notificado (fls. 100/101), o denunciado apresentou defesa prévia, refutando o teor da denúncia (fls. 105/110). Sustentou, em suma, que "o acusado possui histórico de envolvimento com entorpecentes, mas não realiza a sua comercialização, sendo um usuário" (fl. 107). Arroloou testemunhas.

Ausentes causas de rejeição liminar e de absolvição sumária, recebeu-se a denúncia e designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 123/126).

Na solenidade, colheram-se os depoimentos das testemunhas/informantes, interrogou-se o acusado, e, uma vez encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termo e mídia audiovisual da audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/5), nos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 14/15 e 16) e no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 80/83). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidas em poder do acusado quatorze pedras de crack, com massa líquida de 7,93g, além de R\$ 705,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atestou que a substância entorpecente apreendida é causadora de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório. A vinculação do increpado à substância entorpecente é indubidosa.

Nas duas fases da persecução penal (fls. 6/7 e 8 e mídia audiovisual da audiência), os dois policiais militares que realizaram as diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado, Solano Zanette Fernandes de Freitas e Luiz Henrique Garcia Brandão, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram relatos harmônicos. Narraram que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Sebastião Vaz Pereira, numeral 71, Bairro Nova América, quando se depararam com o imputado, que possuía em seu desfavor o mandado de prisão nº 1500029-80.2020.8.26.0452.01.0001-13, expedido por esta Comarca, relacionado à Lei Maria da Penha. Dado cumprimento ao mandado e realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele. Indagado se tinha algo de ilícito na sua residência, localizada na Rua João Dell Agnolo, nº 206, fundos, Bairro Nova América, ele disse que não, autorizando a entrada dos agentes públicos. Em busca na residência, acompanhada pela companheira do imputado, Tatiana, localizaram, no armário da cozinha, quatorze pedras de crack, além da quantia de quase R\$ 700,00 em espécie no armário da sala, em notas fracionadas. No quarto, encontraram uma máquina de lavar de pressão, marca Electrolux, uma máquina de cortar grama, marca Branco, uma lixadeira, sem marca, e uma furadeira, marca Hilti. Indagado, ainda que informalmente, ele disse que a droga (treze porções embaladas e uma maior) se destinava a consumo pessoal. Os objetos utilizados eram novos e estavam guardados, e o acusado disse que havia comprado por um valor menor de terceiras pessoas. Havia denúncias anônimas dando conta de que o acusado praticava tráfico de drogas.

A consorte do acusado, Tatiana Soares, confirmou a abordagem e a busca residencial feita pelos policiais militares. Disse ter visto o momento em que a droga e os objetos apreendidos foram localizados. Aduziu que o dinheiro apreendido era proveniente do trabalho, recebido em espécie, que ele deixava normalmente ali. Soube que o imputado era usuário de drogas após a prisão e trabalhava na roça. Mantém relação afetiva por dois anos. O réu recebia aproximadamente R\$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, por volta do dia 20 do mês. A droga apreendida não

estava fracionada (fl. 9 e mídia audiovisual da audiência).

Sônia Aparecida Soares, mãe do acusado, afirmou que morou com o réu por três meses no endereço dos fatos. Chegou a interná-lo em uma clínica por dependência química. O increpado tem histórico de uso de drogas desde os 13, 14 anos de idade, quando trabalhava e trocava o salário por drogas. Quando ele fez 15 para 16 anos, teve uma hemorragia e admitiu que estava usando drogas. Conversou com uma conselheira tutelar, ocasião em que internou o filho no Recanto Viver, onde ele ficou até os 18 anos. Depois disso, não soube mais se o réu usava drogas. Em 2018, o imputado mudou-se para o endereço dos fatos. O réu trabalhava de segunda a sábado na roça. Não foi mais internado. Não tinha conhecimento que o acusado usava crack.

Marcos Alberto Barbosa, compromissado, contou que comumente via Dornélio passando próximo à sua casa para trabalhar como pedreiro, mas não sabe se ele é usuário ou traficante de drogas.

Gelson Goulart reportou que o réu trabalhou consigo há uns três anos como servente de pedreiro, de segunda a sexta-feira. De lá para cá, não soube de mais nada sobre Dornélio.

Silente na senda policial (fl. 11), interrogado, em juízo, o réu negou a prática do tráfico (mídia audiovisual da audiência). Alegou, em suma, que as pedras de crack se destinavam ao seu uso pessoal. O dinheiro em espécie era fruto do seu trabalho na roça e destinava-se ao pagamento do aluguel. Os instrumentos apreendidos foram comprados de terceiros, mas não sabia que tinham procedência espúria. Foi internado anteriormente para tratamento de dependência química quando era menor de idade.

Teve uma recaída de uns 6 meses para cá, quando passou a fazer uso de crack.

À luz da reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela atividade instrutória, não diviso elementos suficientes que permitam formar um juízo de certeza quanto aos termos da imputação inicialmente feita pelo Ministério Público. Com efeito, os milicianos não presenciaram qualquer ato de comercialização das drogas ou comportamento do qual se pudesse inferir a prática da mercancia ilícita. Ele não foi abordado em local conhecido por ser ponto de tráfico. Nem sequer houve uma confissão informal feita pelo réu aos policiais. Em juízo, o imputado sustentou que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo próprio.

A rigor, a vinculação do acusado parte da premissa de que, juntamente com a droga, foram encontrados outros objetos pretensamente de origem duvidosa na sua residência (uma máquina de lavar de pressão, marca Electrolux, uma máquina de cortar grama, da marca Branco, uma lixadeira, sem marca, e uma furadeira, marca Hilti). Sucede que não se cuida de petrechos usualmente empregados na traficância, e não foram localizados manuscritos contendo possível alusão à contabilidade do tráfico. Foi apreendida quantia em espécie no armário da sala, quantia que, por si só, não é indicativa de traficância. A quantidade de crack apreendida também não era expressiva. O acusado guardava 6,98g de crack (massa líquida), fracionada em quatorze porções.

Enfim, nenhum ato inequívoco de tráfico foi visualizado. Aliás, os policiais indicaram que o único motivo que justificou a abordagem em via pública foi o fato de ter sido expedido em desfavor do acusado o mandado de prisão nº 1500029-80.2020.8.26.0452.01.0001-13.

Nesse quadro, qualquer afirmação de tráfico haveria de partir, necessariamente, de uma presunção, incabível no direito penal. Diante das dúvidas quanto à destinação comercial, deve prevalecer a situação mais favorável à defesa, por influxo dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo, impondo-se a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.303/2006. O próprio réu confessou que teve uma recaída e voltou a usar entorpecentes, tendo a mãe e a companheira aludido ao seu histórico de dependente químico. Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.

1. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Acusado surpreendido na posse de 27 pedras de crack. Ausência de atos de mercancia. Inexistência de efetiva demonstração do vínculo do acusado com o tráfico de drogas. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

2. Dosimetria. Acusado reincidente. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 1501173-78.2022.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 28.09.2022);

Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Possibilidade. Ausência de prova da posse de droga para a finalidade de tráfico. Dosimetria. Prestação de serviço à comunidade considerada extinta pelo tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu. Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 1501940-26.2019.8.26.0400, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 26.09.2022); e

Ação Penal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apreensão de 4,3 gramas de cocaína na forma de crack. Acusado que admite ser usuário de entorpecente. Dúvida razoável sobre o exercício da traficância. Princípio "in dubio pro reo".

Desclassificação do crime para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Admissibilidade.

Necessidade de readaptação penal típica. Réu reincidente, o que justifica a imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, considerada cumprida em razão dele ter permanecido preso desde a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Punibilidade extinta. Recurso provido. (Apelação Criminal nº 1500270-95.2022.8.26.0545, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xisto Rangel, j. 23.09.2022).

Logo, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, tampouco extintivas da punibilidade, a conduta é típica e antijurídica, incidindo, pois, as sanções cominadas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O preceito secundário da norma penal descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 prevê a possibilidade de o magistrado aplicar as seguintes penas: advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (incisos I, II e III). Tais penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como ser substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor (art. 27 da mesma lei). Nessa tarefa, o aplicador deve levar em consideração a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), sem embargo da utilização subsidiária do quanto disposto no art. 59 do CP.

No tocante à duração das penas, a advertência é imediata e instantânea, ao passo que as outras duas serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD), tratando-se de acusado primário, ou de 10 (dez) meses, tratando-se de reincidente (art. 28, § 4º, da LD).

Consoante entendimento recente do STJ, externado pela 6ª Turma no REsp 1.771.304-ES, sob a relatoria do eminente Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019, ao qual me filio, a reincidência, para fins de aplicação do art. 28, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente possibilidade de aplicação das penas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, é apenas a específica. Assentou a Corte Superior de Justiça que a melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é a de que os parágrafos em foco não são unidades autônomas, estando vinculados ao caput do artigo a que se referem.

Joeirados esses critérios, observo que a ínfima quantidade de drogas não enseja maior reprovação penal, e não há informações precisas sobre a personalidade e conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, LVII da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja, ainda, pela peculiaridade de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por

outro delito, consoante consagrado pela jurisprudência pátria. O réu possui condenações definitivas por furto tentado e lesão corporal e invasão de domicílio (fls. 46/49) que encarnam maus antecedentes. Os motivos não merecem maior reprovação, por serem ínsitos à espécie criminosa. As circunstâncias e as consequências do crime não destoaram do ordinário. Não há elementos nos autos para se avaliar a conduta social e a personalidade do réu. Por fim, em razão da natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante dos antecedentes desabonadores, entendo que a medida de advertência, aplicada de forma isolada, não surte o efeito esperado, de maneira que não é suficiente para alcançar a finalidade da norma penal. Reputo ser mais adequada à prevenção e repressão do delito, dentre as duas outras cominadas pelo art. 28 da LD, a medida de prestação de serviços à comunidade.

No tocante à duração da sanção penal, na esteira da motivação supra, o acusado não é reincidente específico, aplicando-se o art. 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, a ditar a aplicação da penalidade pelo prazo de até 5 (cinco) meses. Mercê do antecedente desabonador, aplico a medida no patamar de 4 (quatro) meses.

Em que pese seja indigesta a aplicação da detração nesta etapa processual – tarefa relegada, no mais das vezes, ao juízo das execuções penais –, o réu teve a sua prisão preventiva por mim decretada em 28.06.2022 (fls. 57/61). De lá para cá já transcorreram quase cinco meses. O acusado está preso provisoriamente há tempo superior ao da pena ora imposta, inclusive em situação mais gravosa. Diante dessa sutileza, sopesado o tempo de prisão cautelar imposta ao imputado, aplico a detração anômala, com fulcro no art. 42 do Código Penal, para o fim de declarar extinta a sua punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para, com supedâneo nos arts. 383 e 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR o acusado DORNÉLIO MARCELO LEME, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses. De ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu pelo cumprimento integral da reprimenda imposta.

Por via de consequência, desnecessária a manutenção da custódia. REVOGO a prisão preventiva. EXPEÇA-SE alvará de soltura para que o acusado seja colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso), e não houve requerimento explícito da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Liberem-se os bens e valores apreendidos no auto de fls. 14/15. Quanto aos entorpecentes, DETERMINO que se oficie à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido feito.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de ilegitimidade; e (c) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado. Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

P. I. C.

Piraju, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA